

1500598-95.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... CRIMINAL - Recurso da Defesa - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas - Inadmissibilidade - Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico - Tráfico bem caracterizado pelas provas dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500598-95.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500598-95.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193410/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 19097842 - 03º D.P. AMERICANA, 973/21/346 - 03º

D.P. AMERICANA, 2193410 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 973/21/346 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EMERSON DE JESUS LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

EMERSON DE JESUS LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, vendeu, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (02 porções da droga conhecida como COCAÍNA, pesando 01 grama) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi ofertada as fls. 151/152.

O réu foi citado (fls. 204), apresentando defesa (fls. 193/194).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado. Houve, ainda, a desistência da testemunha Marco (fls. 246/247 e 279/280).

Em seus memoriais (fls. 284/287), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 290/297), requereu a absolvição por falta de provas relativa ao trafico.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, a denúncia atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em falta de justa causa.

Ainda, apenas a título de regularização, considerando a defesa de fls. 193/194, a manifestação do Ministério Público as fls. 205, e não tendo sido suscitada nenhuma das causas previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, que ensejasse a absolvição sumária do acusado, recebo a denúncia de fls. 151/152.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 119/121.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína, de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos. "O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol. Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º graus de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regridam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória". (S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso

(Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento, e na rua dos fatos avistaram, dois indivíduos, sendo que um deles, posteriormente identificado como Emerson, passava algo para o outro. Ao visualizarem a viatura, um deles, posteriormente identificado como Marco, dispensou o objeto recebido ao solo, e ambos saíram andando, disfarçando, na tentativa de evadir-se, mas foram abordados. Em revista, com o réu foi localizada a quantia de duzentos e quarenta e cinco reais, e com o outro foi encontrado apenas um celular. No objeto dispensado, localizaram as duas porções aparentando ser cocaína, e questionado Marco afirmou ser usuário e que teria adquirido a substância entorpecente com Emerson, pagando a quantia de trinta reais. Indagado, o réu negou o delito. Por fim, o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, e o réu já foi abordado no local em outras ocasiões. E, não conheciam Marco.

A pessoa de Marco, ouvida apenas na Delegacia (fls. 11), confirmou a obtenção da substância diretamente com o réu.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – Condenação mantida Penas corretamente fixadas – Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de

Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Impetração visando a absolvição do apelante por fragilidade probatória, com base na negativa de autoria e nas contradições existentes nas versões dos policiais - IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade comprovadas - Negativa de autoria isolada nos autos - Depoimentos dos policiais com pequena contradição referente ao papel do apelante no tráfico que não afeta a decisão condenatória - Testemunhas de defesa que apresentaram declarações com detalhes sequer mencionados pelo apelante, em seu interrogatório - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0004594-74.2014.8.26.0161; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO

DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2.000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

A forma de acondicionamento do tóxico apreendido evidencia a destinação de tráfico.

Ainda que se considere pequena a quantidade que o réu portava, já ficou patente que os "patrões" do tráfico costumam utilizar-se de pequenos traficantes para a venda. Confira-se à respeito, a matéria do Jornal "O Liberal" de Americana, no dia 21 de junho de 2009:

MICROTRAFICANTES VIRAM O PRINCIPAL FOCO

DA POLÍCIA - Os microtraficantes, como são chamadas pela polícia as pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas, são o novo foco dos investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). "Esse tipo de traficante é como

erva daninha. Quanto mais se prende, mais surge. Por isso temos de combatê-los. Queremos chegar no 'patrão' que está no topo e na base da pirâmide do tráfico", disse o delegado Marco Antonio Pozzetti, titular da Dise. Na semana passada, cinco microtraficantes foram presos. Esta forma de comércio foi criada pelos 'patrões' do tráfico para não sofrerem grandes baixas quando a polícia age. Cada micro fica no ponto de venda, conhecido como 'biqueira', com no máximo 20 unidades de entorpecentes (pedrinhas de crack, papelotes de cocaína e pequenos embrulhos de maconha). Eles são abastecidos pelos 'gatos' como os 'patrões' identificam os distribuidores.

"Os investigadores estão saindo às ruas à procura dos microtraficantes. Na quinta-feira, por exemplo, prendemos um que vendia drogas sentado em um sofá na calçada de sua casa, no Jardim Guanabara. Com ele nós encontramos seis pedrinhas de crack, dois pedacinhos de maconha e mais R\$ 30,00. É o exemplo do microtraficante. Ele estava com uma quantidade reduzida". Disse o delegado da Dise. "O surgimento dos microtraficantes é uma forma criada pelos 'patrões do tráfico para evitar grandes tombos. Prendemos muitas pessoas e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Assim, a 'biqueira' não sofre prejuízo", contou o delegado.

Uso próprio

As pessoas que são presas também tentam se beneficiar do artifício da pequena quantidade. Eles procuram provar, na Justiça, que o entorpecente pe para uso. Assim, tentam 'quebrar' a prisão de tráfico para uso de entorpecente. "A maioria alega que estava com aqueles papelotes ou pedrinhas par consumo próprio", afirmou um dos investigadores da Dise. Pozeti instruiu os policiais a agirem nas duas pontas da pirâmide do tráfico. "Os micros estão na base e fazendo prisões. Nós conseguimos enfraquecer e até chegar aos donos do comércio", comentou. Os policiais aproveitam as prisões para fazer um mapeamento do esquema do tráfico em Americana. "Nós já sabemos, por exemplo, quem são os responsáveis pelas principais biqueiras. São informações que surgem com as prisões desses microtraficantes", disse o policial. O perfil do vendedor de pequenas quantidades de droga é diversificado, conforme avaliam os policiais da DISE. São adolescentes, jovens e até crianças. Um numero cada vez maior de mulheres tem atuado nas 'biqueirinhas' como costuma chamar o delegado. (...)Em americana, as prisões aconteceram no Jardim Guanabara, Vila Bela, Parque da Liberdade, São Roque, São Jerônimo e na Praia Azul. (...) "O Jardim Guanabara, em Americana, por exemplo, aparece como uma das áreas de grande concentração de pequenos pontos de venda de drogas e vamos intensificar nosso trabalho" afirmou Pozeti.

Cumprir destacar que o local onde o réu foi preso é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Por fim, a testemunha Thaina, esposa do réu, ouvida sem compromisso, declarou que conhece o réu há cerca de seis anos e sabe que ele é usuário de substância entorpecente. Por fim, o nunca viu o réu envolvido com o tráfico.

O acusado Emerson negou a prática do delito, alegando que foi até o lugar para comprar drogas, e apenas cumprimentou o Marco, sendo que já haviam usado substância entorpecente juntos, momento em que foi abordado pela polícia. Sendo que Marco disse que tinha comprado do depoente. Nega que tenha passado algo para Marcos, estava apenas o cumprimentando.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

O réu alega, mas não comprova que foi até o local apenas para comprar substância entorpecente, fato que, aliado as demais provas e aos depoimentos das testemunhas, torna carente de credibilidade sua negativa de autoria. A alegação não comprovada é também indício que milita em desfavor do réu.

Acerca de eventuais testemunhas, verifica-se que nem mesmo o réu, em seu

interrogatório, indica a existência de outras pessoas no local. No mais, a defesa é livre para produzir as provas e arrolar as testemunhas que acredite necessárias ao ato.

Por fim, o fato do réu já ter sido processado por delito de igual natureza, o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, é indício que fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o *fumus commissi delicti*, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o *periculum libertatis*, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática

do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente específico, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pela certidão de fls. 38/39. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11343/2006, tendo em conta a natureza da droga e a quantidade apreendida. Além disso, o dispositivo é inaplicável ao réu reincidente, ex vi legis.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Uma porque o réu é reincidente, o que impossibilita a adoção de regime mais brando, segundo a jurisprudência:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência específica. Regime fechado. Tratando-se de réu reincidente específico, posto que agora condenado a pena de cinco anos de reclusão, outro não há de ser regime prisional de cumprimento inicial que o fechado. (TJSP; Apelação Criminal 0001074-91.2017.8.26.0617; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 08/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso da Defesa - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas - Inadmissibilidade - Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico - Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos - Regime prisional mais brando - Inadmissibilidade - Acertado o regime prisional fechado para o réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente, merecendo tratamento penal

mais severo - (...) - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500257-28.2018.8.26.0613; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Além disso, nos termos do entendimento da jurisprudência (TJSP, 993.07.126969-7, 6ª Câmara, Rel. Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. 25.02.201), de acordo com a Lei nº. 11.464, de 28 de março de 2007, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise do eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão. Se assim não fosse, não teria sentido algum outro regime a ser fixado. O legislador, ao tratar o traficante de drogas equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis, como fiança, indulto, sursis, liberdade provisória etc. Assim, não faria sentido que, condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso ao fechado.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO, AINDA QUE EM SUA MODALIDADE "PRIVILEGIADA". REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1) A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei nº 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos "inter partes", não se registrando declaração de inconstitucionalidade "erga omnes" dos indicados dispositivos - Precedente do C. STJ - Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Compatibilidade, de qualquer forma, com a gravidade concreta dos fatos. 2) Substituição da corporal por restritivas de direitos - Impossibilidade - Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de pena restritiva de direitos - Art. 44, III, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 0009095-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)

Assim também se posicionou a 7ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"No tocante ao regime prisional, deve prevalecer o fechado, por força de expressa previsão legal e o montante das penas carcerárias inviabiliza eventual substituição por restritivas de direitos. Afinal, os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade ordeira". (Relator Des. Roberto Mortari, j. 22.05.2014).

O réu poderá apelar em liberdade, por estar respondendo solto ao presente processo, e por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu EMERSON DE JESUS LIMA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa no piso, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos valores e objetos apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença. P. I. C.

Americana, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA